

1507837-95.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... do fechado; o afastamento de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo; a não aplicação da agravante da calamidade pública; a aplicação da menor fração, em caso de reconhecimento do concurso formal; possibilidade de recorrer em liberdade; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e o reconhecimento da incidência da detração.

É o relatório. Fundamento e decidido.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1507837-95.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507837-95.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DE OLIVEIRA BACKSCHAT

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

WESLEY DE OLIVEIRA BACKSCHAT (RG 49478059-SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j (calamidade pública), por quatro vezes, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, porque, no dia 29 de março de 2021, por volta das 15h, em ocasião de calamidade pública, na Rua Hércio da Silva, 358, Brasilândia, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com três indivíduos não identificados, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, 04 (quatro) aparelhos de telefone celular, além do valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas Rafael Ferreira da Silva, Felipe Ferreira da Silva, Vitoria Gabriela de Souza Pereira e Lucélio Inácio dos Santos. O acusado foi preso em flagrante (fls. 05).

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo juízo de plantão (fls. 70/73).

A denúncia foi recebida (fls. 92/93).

O acusado foi citado (fls. 103) e apresentou resposta à acusação (fls. 105/117).

Sobreveio a decisão que manteve o recebimento da denúncia (fls. 135/136).

A defesa requereu a concessão de liberdade provisória (fls. 144/149). O pedido defensivo foi negado e a prisão provisória mantida (fls. 154).

Durante a primeira audiência de instrução, foram ouvidos dois policiais arrolados pela acusação.

Quando da segunda audiência de instrução, uma testemunha policial foi reinquirida.

Durante a terceira audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pela Defesa. Ao final, houve o interrogatório do acusado.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação do regime inicial diverso do fechado; o afastamento de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo; a não aplicação da agravante da calamidade pública; a aplicação da menor fração, em caso de reconhecimento do concurso formal; possibilidade de recorrer em liberdade; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e o reconhecimento da incidência da detração.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 16/27), auto de apreensão (fls. 08), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

As vítimas Rafael Ferreira da Silva, Felipe Ferreira da Silva e Vitoria Gabriela de Souza, em sede policial, afirmaram que, ao localizarem um anúncio de veículo no site OLX, saíram de Cotia e se dirigiram à Rua Élcio da Silva, nº 358, Vila Teresinha, para comprá-lo. Relataram que, ao chegarem, foram informados que o endereço do anúncio não correspondia àquela área. Aduziram que, passados alguns minutos, foram surpreendidos por quatro pessoas, sendo três portando armas, e foram obrigados a se deitarem no chão, sob a mira delas, sendo que lhes foram subtraídos quatro aparelhos celulares e o valor de R\$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais). Narraram que, restituída a liberdade, dirigiram-se à viatura. Na delegacia de Polícia, realizaram o reconhecimento pessoal positivo, indicando o agente WESLEY DE OLIVEIRA BACKSHAT como o autor do roubo.

Em juízo, a vítima Rafael Ferreira da Silva reconheceu o réu como um dos roubadores, e narrou que as vítimas saíram de Embu das Artes e foram comprar um carro anunciado na OLX, e chegando no endereço indicado, o vendedor não era conhecido no local. Disse que havia um motoqueiro que passou observando e logo depois apareceram 4 pessoas que anunciaram o assalto. Aduziu que os assaltantes sabiam do combinado, pois diziam que sabiam que as vítimas eram de Embu das Artes. Afirmou que as vítimas deitaram no chão e entregaram dinheiro e telefones celulares. Informou que depois conseguiram pedir ajuda a policiais, que foi até o local dos fatos, e depois conseguiram pegar o indivíduo. Afirmou que um estava com uma pistola, outro com uma arma de brinquedo e outro com um de calibre 38. Aduziu que iam deixar um celular para trás, mas acabaram voltando e pegando o celular, com medo de chamarem a polícia. Disse que o réu, que foi quem rendeu a vítima Vitória Gabriela, estava sem máscara. Confirmou que conseguiu recuperar o aparelho celular, que estava com o réu. Disse que demorou meia hora entre a comunicação aos policiais e a prisão do réu. Informou que eram dois brancos, e um que estava parando o trânsito, e usava boné, era moreno. Disse que não reconhece o condutor da motocicleta, pois estava de capacete, mas acha que estava envolvido no roubo, por ter passado olhando muito para as vítimas.

Em juízo, a vítima Felipe Ferreira da Silva reconheceu o réu como um dos roubadores e narrou que foram comprar um carro que seu irmão, Rafael, tinha visto no OLX, e, chegando ao local, seu irmão ligou ao rapaz, o qual avisou que estava chegando. Disse que passou uma moto olhando para eles, despertando desconfiança, e depois chegaram 4 pessoas, armadas, que anunciaram o assalto. Aduziu que os ladrões renderam as vítimas e falaram para entregar dinheiro, caso contrário levariam o carro, e também levaram os telefones celulares. Disse que conseguiu pedir ajuda a policiais, que estavam numa oficina arrumando um pneu, e que pouco tempo depois

retornaram com um rapaz com quem foi apreendido o celular de seu irmão. Afirmou que o réu era o indivíduo que estava do outro lado apontando a arma, sem máscara. Em juízo, a vítima Vitoria Gabriela de Souza reconheceu o réu como um dos roubadores e narrou que chegaram no local para comprar o carro, e o rapaz não estava no local, mas decidiram aguardar. Disse que logo após chegaram 4 indivíduos e anunciaram o assalto, pedindo o dinheiro e os telefones celulares. Afirmou que já sabiam do dinheiro, que estava com ela, e ela disse que estava no cartão, mas eles insistiram para que o dinheiro fosse entregue, caso contrário levariam o carro. Confirmou que o dinheiro (R\$2.500,00) era para comprar o carro. Disse que o réu estava com uma arma e apontou a arma. Ela foi a única pessoa com quem os criminosos não mexeram, e o réu somente pegou o celular que estava sobre sua perna. Afirmou que olhou bastante no rosto do réu, que estava sem máscara. Disse que a vítima Rafael foi a única que não ficou sem o celular. Indagada, esclareceu que na verdade ele foi roubado, mas conseguiu recuperar o aparelho após a prisão do réu. Em sede policial, a vítima Lucélio Inácio dos Santos ratificou as declarações extrajudiciais dos demais ofendidos. Entretanto, ao realizar o procedimento de reconhecimento pessoal, não reconheceu conclusivamente WESLEY como autor do roubo. Em juízo, a vítima Lucélio Inácio dos Santos reconheceu o réu como um dos roubadores, e narrou que o réu já tinha passado de moto e foi o primeiro que chegou e pediu para deitar no chão. Disse que depois chegaram mais 3 indivíduos. Afirmou que não estavam de máscara e 3 estavam armados. Confirmou que roubaram o celular dele. Disse que, após o acontecido, a mãe do réu, acompanhada de uma advogada e mais duas outras pessoas, foram na casa da irmã dele procurando a vítima Vitória Gabriela, que é sua enteada. Informou que demorou em torno de meia hora para que a polícia capturasse o réu e os chamasse para a delegacia, onde naquela ocasião não conseguiu fazer o reconhecimento. Aduziu que posteriormente conseguiu se lembrar de que o réu era a pessoa que tinha passado de moto e depois retornou sem moto, com outras 3 pessoas, quando anunciaram o assalto. Os policiais militares Michel Ribeiro Martins e Cassio Martins Rodrigues afirmaram, extrajudicialmente, que, em patrulha pela Av. Dep. Cantídio Sampaio, foram acionados por vítimas de roubo, e se dirigiram à Av. Joaquim Rodrigues de Moura, nº 39, bairro Vila Teresinha, onde havia ocorrido o roubo, por volta das 16h. Aduziram que as vítimas alcançaram a viatura, dizendo que foram roubadas por quatro pessoas armadas, em uma localidade próxima. Relataram que, após terem as características físicas em mãos, iniciaram o procedimento de busca, logrando êxito em encontrar um dos elementos na Rua Joaquim Rodrigues de Moura, nº 39; que diante da autorização de entrada na residência de sua mãe, fornecida por Emerson de Oliveira Backschat e confirmado em relato ao policial civil, encontraram na posse de WESLEY DE OLIVEIRA BACKSCHAT um dos celulares objeto do roubo, de propriedade de uma das vítimas, devidamente apreendido. Em juízo, a testemunha policial Michel Ribeiro Martins informou que estava em patrulhamento quando se deparou com 4 vítimas que informaram que acabaram de ser roubadas por 4 indivíduos, e disseram que caíram num golpe da OLX. Narrou que, com as características passadas pelas vítimas (branco com olhos claros), se depararam com o réu, que correu para dentro de uma residência. Disse que o irmão franqueou a entrada, e o réu já estava no banheiro, retirando a roupa. Na casa ainda se encontravam a mãe e uma irmã do réu. Conduziram o réu até a delegacia, onde três das quatro vítimas reconheceram o réu, sem sombra de dúvida. Informou que o seu colega encontrou o celular, que foi reconhecido pelas vítimas na delegacia. Segundo ele, o réu não disse nada quando foi preso, somente falou na delegacia. Afirmou que uma das vítimas, Lucélio, telefonou no dia seguinte no batalhão para saber como proceder, pois, segundo ela, o irmão do réu teria a procurado em sua residência. Em nova oitiva, em juízo, em razão de problema no áudio da primeira audiência, o policial Michel informou que estavam em patrulhamento perto ao local quando se deparou com 5 vítimas que disseram ter sido roubadas, e passaram as características dos indivíduos. Afirmou que iniciaram o patrulhamento e quando o réu avistou a viatura, ele adentrou uma residência correndo (depois soube que era a residência do réu). Disse que também adentraram a residência, que estava aberta, e se depararam com o irmão do réu, para quem perguntaram se tinha visto alguém entrando ali

correndo, e o irmão disse que não viu, mas permitiu a entrada dos policiais. Afirmou que o réu estava dentro do banheiro sem a roupa e, perguntado se tinha roubado alguma coisa e a razão de ter fugido, o réu não quis informar, e o outro policial, parceiro da testemunha, encontrou o celular jogado no chão. Aduziu que conduziu o réu à delegacia, e as vítimas reconheceram o réu. Disse que o celular era de uma das vítimas, e o réu não esclareceu porque estava com o celular da vítima. Informou que, segundo as vítimas, o crime houve a participação de 3 a 4 pessoas, e que houve a utilização de armas, e todas as vítimas foram agredidas. Disse que as vítimas caíram num golpe. Afirmou que uma das vítimas o procurou, por telefone, dizendo que o irmão do réu foi até o endereço da vítima para tentar amedrontá-la, mas não conseguiu contato.

Em juízo, o policial Cassio Martins Rodrigues informou que estava em patrulhamento e foram abordados por quatro indivíduos que disseram terem sido vítimas de roubo, e com a descrição recebida, tanto das características físicas quanto das vestes, viu o réu adentrando uma residência. Afirmou que o irmão da vítima, que estava no portão, franqueou a entrada na casa, e o réu já estava no banheiro tomando banho. Disse que um aparelho telefônico estava junto com as vestes do réu, no banheiro. Aduziu que conduziu o réu até a delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas, assim como o celular. Informou que o réu negou a autoria, pois tinha acabado de chegar e estava trabalhando. Disse ainda que tanto o irmão, quanto a mãe do réu, que também estava na casa, disseram desconhecer o que estava acontecendo.

Em juízo, a testemunha arrolada pela Defesa, Amanda Beatriz dos Santos Toledo, disse que é cunhada e mora no mesmo quintal que o réu, que reside na casa de cima, e no dia dos fatos o réu, que trabalha entregando marmita, já tinha chegado do serviço. Logo após viu que os policiais já estavam no quintal, falando que tinha havido um assalto, e perguntando se tinha visto alguma pessoa entrando ali, o que ela negou. Disse que acordou o seu marido, a pedido dos policiais, e este também não tinha visto ninguém entrando, mas acompanhou os policiais para verificar até na casa da sua sogra. Aduziu que levaram o celular do réu.

Em juízo, a testemunha Emerson de Oliveira Backchat narrou que é irmão do réu e no dia dos fatos chegou do serviço, e estava deitado dormindo, e acordou com os policiais na porta de seu quarto, que perguntavam se tinham visto alguém entrando na casa, e perguntaram se poderiam procurar. Disse que eles olharam e não acharam nada, mas foram até a casa do seu irmão, e prenderam o réu. Informaram que um dos policiais estava com a foto do réu no telefone celular, e que este mesmo PM já tinha abordado o réu em outra ocasião, e acredita que seja uma retaliação deste PM. Afirmou que seu irmão sempre foi trabalhador e nunca se envolveu com coisa errada. Aduziu que levaram o celular do réu e não devolveram.

Em juízo, a testemunha Rosana Rosa de Oliveira narrou que é mãe do réu e no dia dos fatos estava trabalhando normalmente e ouviu quando este chegou do serviço e estava conversando ao telefone e entrou no banheiro. Ouviu seu filho mais velho perguntando se tinha visto alguém entrando na casa. Disse que logo após entrando os policiais anunciando a prisão do seu filho, e ele reconheceu um dos policiais de uma ocorrência anterior. Afirmou que seu filho é exemplar, que nunca se envolveu com coisa errada.

Em juízo, a testemunha Douglas Lopes da Silva disse que o réu é seu vizinho e que trabalhava em sua marmitaria. Informou que o réu saiu do trabalho, que fica perto da sua residência, entre 3h38min e 3h40min.

Interrogado em sede policial, o acusado WESLEY DE OLIVEIRA BACKSCHAT negou qualquer participação no roubo. Afirmou que, na data dos fatos, estava trabalhando no marmitex Tempero da Érica, na Rua Alfredo Lúcio, saindo por volta das 15h50 e retornando para sua casa. Relatou, ainda, que estava tomando banho quando avistou duas viaturas defronte à residência, que divide com a mãe e irmã, e que os policiais disseram "você está preso", em razão de "ter roubado R\$ 2.000 (dois mil reais)". Aduziu que não fora autorizado o ingresso na residência e que seu irmão Emmerson reside no andar de baixo da casa.

Em juízo, o réu negou os fatos e disse que uns dias antes foi abordado em frente ao seu portão pelo policial Michel e foi perguntado sobre um tal de Daniel, que ele diz desconhecer, contrariando o policial. No dia dos fatos, chegou em casa e após

conversar com a esposa, depois de uns 10 minutos, foi tomar banho. Logo após chegou o policial Michel dizendo que ele estava preso. Informou que o policial pegou o seu celular, que está apreendido até agora e, na viatura, pediu a senha do aparelho e viu que não tinha nenhum contato do Daniel. Aduziu que, lá na Delegacia, ficou esperando e viu os policiais chegando conversando com duas vítimas, as quais fez gestos demonstrando que teriam o reconhecido. Disse que o policial insistia para que o réu entregasse o indivíduo conhecido como Daniel. Informou que do local dos fatos até sua casa, seria uns 3 minutos, menos de um quarteirão e do marmiteix até sua casa tem uns 50 metros. Afirmou que, quando os policiais chegaram, já estava no banho há uns 5 minutos. Disse que o único celular que o policial apreendeu foi o seu celular pessoal. Afirmou que não conhece as vítimas.

Pelo conjunto probatório restou comprovada a conduta criminosa imputada ao réu. O reconhecimento pelas vítimas e a apreensão de um dos celulares subtraídos, logo após o crime e dentro da residência do autor, confirmam a autoria. Ainda que exista dúvida quanto a um dos ofendidos, que não tinha reconhecido o réu, na fase policial, como um dos autores do delito, só o fazendo em juízo, as demais vítimas foram categóricas em seu reconhecimento.

Como é cediço, as palavras do ofendido não devem ser desqualificadas, principalmente em casos de crimes patrimoniais nos quais não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor de suas declarações.

Nesse sentido: É clara a posição destacada pelo d. Procurador de Justiça, de que o depoimento da vítima, quando se trata principalmente de crimes contra o patrimônio, é extremamente importante e válido, sendo que esta tem total interesse em localizar o verdadeiro culpado. Saliente-se que em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera sobre as negativas dos acusados, sendo preciosa e bastante no identificar os autores do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TJSP, Apelação Criminal nº.990.08.074385-6, 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Marcus Zanuzzi, julgado em 04/12/2008).

Eventuais questões surgidas durante a instrução, como a dúvida se o réu realmente empreendeu fuga ao avistar os policiais, não inibem o convencimento sobre a autoria haja vista que tais dúvidas não atingem pontos essenciais do conjunto probatório. Ademais, não ficou delineado o problema preexistente entre o réu e um dos policiais que fez a abordagem, como narrado por algumas das testemunhas arroladas pela defesa. Não se coloca em dúvida a existência ou não do problema ocorrido semanas antes. O fato é que o réu foi reconhecido pelas vítimas, de modo que, mesmo que tenha existido esse problema com o policial, não se pode desprezar o reconhecimento realizado com segurança pelos ofendidos.

Outrossim, não se comprovou que o réu estaria trabalhando no horário que ocorreu o roubo, com a juntada, por exemplo, de cartões de ponto, imagens do local do trabalho ou outros meios de prova.

Ficou comprovado também que, no ato do roubo, houve o emprego de armas de fogo para constranger as vítimas, mediante grave ameaça. Muito embora as armas não tenham sido apreendidas, a palavra das vítimas é suficiente para a incidência de tal majorante, pois, "o reconhecimento da causa do emprego de arma não depende da apreensão e perícia do artefato, se comprovada pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal" (STJ AgRg no REsp 1413231/MG, Relª. Minª. Marilza Maynard, Sexta Turma, DJe 30/09/14; HC 204247, Rel. Minª Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02/10/12; e HC 192831, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/04/12).

Nesse sentido, ressalta-se que todas as quatro vítimas confirmaram que os agentes estavam armados, de modo a afastar qualquer dúvida a respeito da incidência da majorante em comento.

Restou igualmente comprovado o concurso de agentes, ante o teor dos depoimentos dos ofendidos.

Destarte, restam comprovadas as causas de aumento de pena presentes na denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Passo à dosimetria da pena.

Fixo a pena-base para o crime de roubo no mínimo legal, isto é, em 04 anos de

reclusão e 10 dias-multa, no piso, pois não há circunstâncias judiciais que justifiquem seu aumento. Anote-se que, com base nas provas produzidas, todas as circunstâncias que aumentam o grau de reprovabilidade da conduta do acusado serão contempladas pelas agravantes e majorantes a serem consideradas, bem como pela aplicação do artigo 70 do Código Penal.

A agravante constante do artigo 61, II, j, do Código Penal deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "naufrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "naufrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "naufrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor e/ou demonstre certa fragilidade da vítima quando da conduta, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigorem 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavirus disease 19 COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade objetiva, o que não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica ou não ficou demonstrado que a vítima estava numa situação mais vulnerável em decorrência da pandemia. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66, CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afastou a agravante mencionada pelo Ministério Público na peça vestibular.

Diante do exposto, na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, conjugam-se duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, uma constante no §2º, inciso II (concurso de agentes), além do §2º-A (emprego de arma de fogo), todos do artigo 157, do Código Penal. Comumente, para o caso, aplicar-se-ia a regra aritmética do parágrafo único do artigo 68, do Código Penal. Ocorre que esse raciocínio sempre levaria à aplicação fixa da maior fração de aumento, a saber, 2/3. Isso fere o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º XLVI), na medida em que haveria um raciocínio prévio de que o uso da arma de fogo é um fato objetivo que não demandaria maiores considerações em cada caso concreto, de modo que bastaria o indivíduo praticar o roubo armado para que o aumento da maior fração incidisse. No entanto, não se desconhece que o uso da arma de fogo varia de caso a caso, de modo que não se pode dar o mesmo aumento de pena para pessoas que se utilizaram da arma de fogo com intensidades diversas. Então, cabe ao julgador avaliar em cada situação qual foi a intensidade do uso da arma de fogo. Outro aspecto que precisa ser ponderado é que o parágrafo único do artigo 68 não traz uma norma cogente como alguns defendem, na medida em que a expressão "pode o juiz" demonstra bem a intenção do legislador de respeitar a individualização da pena, de modo que deve ser entendida como faculdade do julgador. Por outro lado, é certo que o parágrafo único do artigo 68 ao fazer referência de que o juiz pode "limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua" estaria fazendo comparações de critérios semelhantes de aumento; porém, observa-se que o §2º, inciso II, do artigo 157 indica parâmetros fracionários variáveis de aumento (a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade), enquanto que o §2º A, do mesmo dispositivo legal refere-se a parâmetro fixo (a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)); então, no caso específico, estaríamos diante de escolha de parâmetro fracionário distinto e, naturalmente, sempre que ocorresse um roubo a mão armada a fração fixa seria sempre de 2/3, violando de morte o já citado princípio da

individualização da pena, bem como o princípio da proporcionalidade na sua vertente de proibição do excesso, uma vez que em situações mais "brandas" no uso de arma de fogo o aumento da pena seria sempre o mesmo. O ideal, do ponto de vista constitucional, é interpretar que os dois terços fixados pelo legislador indicam apenas o máximo em que o intérprete pode chegar quando ocorrer o uso de arma de fogo, podendo este avaliar caso a caso.

No caso, trata-se de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, porém a arma foi empregada de modo ostensivo, sendo certo que as vítimas foram mantidas sob a mira dos roubadores enquanto seus pertences eram subtraídos. Desse modo, aumento a pena do réu em 3/8, considerando os argumentos acima sobre a questão da arma de fogo, bem como o concurso de agentes, entendendo-se que, no conjunto das majorantes, a fração de aumento é proporcional ao caso.

Não há causas de diminuição da pena.

Outrossim, indubitável a configuração do concurso formal, uma vez que foram subtraídos pertences de quatro vítimas distintas, motivo pelo qual aumenta-se a pena em mais $\frac{1}{5}$, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Então, a pena definitiva será de 06 anos, 07 meses e 6 dias de reclusão.

O réu deverá cumprir a pena em regime inicial semiaberto nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu WESLEY DE OLIVEIRA BACKSCHAT (RG 49478059-SP) como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, por quatro vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida nos termos do artigo 1º, inciso III e artigo 5º, inciso III, da Constituição Federal.

O réu deverá permanecer preso porque presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública (anotando-se que o fato é relativamente recente), especialmente diante da grave ameaça empregada no caso concreto, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação. Expeça-se guia de execução provisória com urgência em relação ao réu, especialmente por ter sido condenado ao regime semiaberto, visando que ele seja transferido ao regime adequado com a maior brevidade, situação que será acompanhada pelo Juízo da Execução Criminal competente.

Fica autorizada a restituição do aparelho celular do réu, apreendida a fls. 33. P.I.C.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA